

SENTENCIA

Córdoba, cinco de marzo de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Estos autos caratulados “**V., M.L. C/ D’A, O.M. y/otro – ordinario - daños y perjuicios - mala**

praxis - Exp. ...”, de los que resulta.

1) Con fecha 18/05/2016 comparece la Sra. M.L. V., con el patrocinio letrado de los Dres. Norma Gladys Ferreyra y Andrés R. Ricaldone y promueve demanda ordinaria de mala praxis en contra del médico Dr. O.M. D’A y en contra de la Clínica Sucre Centro de Cuidados Coronarios S.R.L. persiguiendo la reparación integral de los daños y perjuicios ocasionados. Reclama, la suma de pesos setecientos noventa y siete mil cuatrocientos doce con treinta y seis centavos (\$ 797 412,36) o lo que en más o menos surja de la prueba a rendirse en la causa, con más intereses desde que cada rubro se ha tornado exigible y costas. Asimismo, reclama los honorarios dispuestos en el art. 104 inc. 5 de la ley 9459. En su alegato reajusta la pretensión a la suma de pesos veintitrés millones trescientos treinta y siete mil quinientos treinta y dos con doce centavos (\$ 23 337 532,12).

Manifiesta, que la demanda tiene su origen en la actuación médica defectuosa dada por el Dr. O.M. D’A que incurrió en un grave error en una cirugía de vesícula realizada en la Clínica Sucre, lo que derivó en innumerables complicaciones y cirugías posteriores.

Relata, que a principios del año 2007 comenzó con dolores estomacales, por lo que consultó con el médico Dr. O.M. D'A quien le aconsejó realizar una cirugía de vesícula a través de la técnica laparoscópica.

Manifiesta, que el 04/09/2007 se internó en la Clínica Sucre, tal como lo habían acordado con el médico tratante y fue intervenida quirúrgicamente por el mismo, dándola de alta al día siguiente, aún cuando se sentía muy dolorida. Relata, que a los dos días de la cirugía comenzó a sentirse peor, con mucho dolor abdominal, algunas líneas de fiebre, hinchazón del abdomen, náuseas y vómitos. Además, empezó a notar una tonalidad amarillenta en su piel. Indica, que ante esos síntomas se comunicó telefónicamente con el médico en varias oportunidades, en las que el demandado restó importancia a los síntomas y le dijo que todo estaba perfecto. Relata asimismo, que concurrió varias veces de *motu proprio* a la Clínica Sucre, oportunidades en las cuales el médico solo le prescribió calmantes y recién a los 10 días de pasada la cirugía le solicitó análisis de laboratorio y una ecografía abdominal. Indica, que el 13/09/2007 al constatar por la ecografía un derrame biliar en peritoneo le prescribió antibióticos. Indica, que los días posteriores comenzó a sentirse cada vez peor, que prácticamente no podía ingerir alimento ni líquido alguno y tampoco podía caminar, motivo por el cual se comunicó con el médico tratante, quien le solicitó que volviera a la Clínica Sucre para una nueva intervención quirúrgica. Explica, que el médico le indicó que esta segunda cirugía sería sencilla, que duraría entre una hora y media o dos horas como máximo y que solo haría una incisión de 5 cm. aproximadamente, con la finalidad de extraer el líquido acumulado. Sostiene, que luego de que salió del quirófano y reaccionó de la anestesia, se enteró (por sus parientes) que estuvo en el quirófano por 5 o 6 horas, que le colocaron dos drenajes y además advirtió que la cicatriz que le quedó fue de 15 cm. aproximadamente.

Indica, que el Dr. O.M. D'A en todo momento engañó a la actora y su familia, en relación a lo que había sucedido en las dos cirugías, (como ella lo pudo advertir recién luego de la segunda), puesto que siempre le contestaba con evasivas, adjudicando las complicaciones postoperatorias a un supuesto mal congénito que padecía la compareciente, como el denominado "Mal de Mirizzi", que consignó el médico en la foja quirúrgica de la segunda cirugía, lo que no fue cierto.

Continúa relatando, que mientras estaba internada, como continuaba en delicado estado de salud, sus padres se comunicaron con un tío el Dr. G.T., quien es médico cirujano y especialista en gastroenterología, el cual se apersono en la Clínica Sucre y logró hablar personalmente con el accionado. Indica, que en esa conversación el médico demandado ya no pudo sostener sus mentiras ante su colega médico y especialista y le confesó que en la primera cirugía ligó el conducto colédoco con el conducto cístico y seccionó el conducto hepático común que quedó desconectado del colédoco, y que es de ese segmento que drenaba bilis al perinoteo. Asimismo, le confesó que en la segunda intervención no logró reparar la vía biliar y por ello, dejó un drenaje en el conducto hepático para que drenara la bilis hacia el exterior. Ante ese panorama, su tío se comunicó con el Dr. M.C., quien a su entender tendría los conocimientos especializados suficientes para reparar el grave error que había cometido el accionado en la primera cirugía, quien aceptó tratarla en el Sanatorio Allende.

Así las cosas, explica que firmó el alta médica en forma voluntaria para retirarse de la Clínica Sucre el 18/09/2007 y ese mismo día fue trasladada en ambulancia al Sanatorio Allende donde luego de hacerle estudios y valorarla, el día 19/09/2007 le colocaron un catéter venoso central en su cuello, por la necesidad de reposo gastrointestinal. Continúa relatando, que el 21/09/2007 le hicieron otra ecografía y descubrieron que había colectado

bilis, por lo que ese mismo día ingreso a quirófano por tercera vez, pero esta vez en el Sanatorio Allende y a cargo del Dr. C. (su nuevo médico) en esta intervención se lavó la cavidad y se le colocaron dos nuevos drenajes, es decir, pasó a tener 4 drenajes colocados y fue dada de alta el 29/09/2007 con 1 solo catéter colocado. Continúa relatando, que desde el día 02/10/2007 hasta el 05/10/2007 estuvo internada nuevamente en el Sanatorio Allende para la colocación de otro catéter para drenaje. Y que finalmente, el día 31/10/2007 la operó el Dr. C. en el Sanatorio Allende (cuarta cirugía), con finalidad reconstructiva y que luego de realizar una punción el día 06/11/2007 (porque nuevamente había colectado líquido), recibió el alta sanatorial el día 11/11/2007. Manifiesta, que tuvo un drenaje (con todas las complicaciones que ello supone) hasta el día 20/11/2007, fecha en la cual lograron retirarlo. Relata, que luego de esa fecha y durante algunos años más, continuó con controles periódicos hasta el día de la demanda, en la que una vez al año debe hacerse estudios clínicos, continúa con una dieta estricta en las comidas, sufre de acidez estomacal, reflujo, dolor de cabeza, hinchazón abdominal e intolerancia a antibióticos y antiinflamatorios.

Aclara, que durante todo el tiempo que pasó entre la primera vez que la operó el demandado (04/09/2007) hasta que recibió el alta en el Sanatorio Allende (20/11/2007) su vida se convirtió en un suplicio, porque estuvo muy medicada, además por que debió utilizar faja abdominal, vendas en las piernas, drenajes, catéteres, que muchas veces ella sola debía administrar y controlar. Además, tenía muchas cicatrices. Con lo que, vivía prácticamente recluida y abocada a estas cuestiones con el lógico pesar psicológico por la gran angustia que todo le provocaba. Además, sostiene que todo el episodio relatado tuvo gran incidencia en su carrera y en su trabajo.

Arguye, que el Dr. O.M. D'A incurrió en mala praxis médica, puesto que en la primera cirugía cometió una injuria quirúrgica de las vías biliares Tipo I o II de Bismuth, según lo indicaron los peritos oficiales que dictaminaron en sede penal, puesto que se vio obligada a realizar una denuncia penal en contra del médico por todo lo sucedido. Esa injuria quirúrgica consiste en que seccionó el conducto hepático común dejándolo abierto a la cavidad y ligó el conducto colédoco juntamente con el cístico, sin advertirlo en la laparoscopia, toda vez que no utilizó ningún método recomendado por la medicina para identificar los conductos y no cometer ese grave error, como es la colangiografía intraoperatoria.

Fustiga además, la conducta post operatoria del médico tratante, porque sostiene que luego de la cirugía menospreció el cuadro inmediato posterior, el que debería haberle dado indicios de que había ocurrido una lesión biliar y se demoró en programar la segunda intervención, poniendo en grave riesgo su vida. Además, sostiene que en la segunda cirugía tampoco utilizó un método para reparar la vía biliar, solo limpió la cavidad y dejó un drenaje para que drene la bilis al exterior. Reclama también, que luego de la segunda cirugía el médico le ocultó información a ella y a su familia y que también falseó maliciosamente información, porque en la foja quirúrgica de la segunda cirugía consigno que la actora padecía de Síndrome de Mirizzi, lo que no era cierto.

En cuanto a la responsabilidad de la Clínica Sucre, explica que debe responder solidariamente con el médico demandado, porque tiene a su cargo una prestación primaria de servicio de asistencia médica, en la que debe preservar al paciente de todos los daños que puedan derivarse de esa relación contractual, unido a una obligación tácita o accesoria de seguridad en relación a la prestación médica con el paciente y además, su responsabilidad es refleja por el accionar de su dependiente.

Cita jurisprudencia.

Reclama, en concepto de gastos generales la suma de pesos (error de tipeo mediante) diez mil (\$ 10 000), por tratamiento psicológico la suma de pesos ciento treinta y dos mil cuatrocientos (\$ 132 400) lo que en el alegato reajusta a la suma de pesos doscientos cuarenta y siete mil doscientos (\$ 247 200), por indemnización por incapacidad reclama la suma de pesos quinientos sesenta mil doce con treinta y seis centavos (\$ 560 012,36), lo que en su alegato desdobra y reajusta a lucro cesante pasado en la suma de pesos setecientos sesenta mil doscientos setenta y nueve con veintiséis centavos (\$ 760 279,26) y lucro cesante futuro la suma de pesos diez millones cuarenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y dos con ochenta y seis centavos (\$ 10 047 452,86). Finalmente, por daño moral reclama la suma de pesos cien mil (\$ 100 000) y en su alegato reajusta sustancialmente a la suma de pesos doce millones doscientos setenta y dos mil seiscientos (\$ 12 272 600). Funda su demanda en derecho.

2) Impreso el trámite de ley a f. 67 y citados los demandados a comparecer, a ff. 69/71 comparece la demanda Clínica Sucre Centro de Cuidados Coronarios S.R.L. (en adelante Clínica Sucre) con el patrocinio letrado del Dr. Fabián Gabriel Barbera y cita en garantía a su aseguradora Noble Compañía de Seguros S.A. A f. 75 comparece el demandado Dr. O.M. D'A con el patrocinio letrado del Dr. Gastón E. Acevedo. A ff. 96 comparece la citada Noble Compañía de Seguros S.A. con el patrocinio letrado del Dr. Fernando Careto Loza y de la Dra. Celia Elisa Cerutti

3) Corrido traslado de la demanda con fecha 13/10/2016, el mismo es evacuado por el demandado Dr. O.M. D'A a ff. 100/117. Pide el rechazo de la demanda, con costas. Niega todos y cada uno de los hechos afirmados en la demanda, excepto los que sean objeto de expreso y especial reconocimiento. Impugna documental.

Preliminarmente, sostiene que la actora no explica específicamente cuales son los actos médicos realizados por el, que pudieran ser considerados como mala praxis médica. Señala, que la actora nunca explicó que decisión hubiera tenido que tomar el médico y que ella misma en su demanda reconoció que la responsabilidad médica es de medios y no de resultado. Sostiene, que todos los procedimientos fueron correctos y no hubo mala praxis. Explica, que la paciente presentó una litiasis biliar sintomática, frente a la cual había dos opciones plenamente válidas, una la cirugía tradicional y otra por videolaparoscopia, que el eligió esta última por ser la más aconsejada en estos casos para extracción de vesícula. Explica, que la actora tenía plena conciencia y conocimiento de los riesgos del acto quirúrgico y las eventuales complicaciones que podía presentar. Sostiene, que en la primera cirugía se produjo una lesión de la vía biliar, que es una de las complicaciones que pueden surgir en este tipo de cirugía y que suelen pasar inadvertidas en la misma laparoscopia en la gran mayoría de los casos y que solo se evidencia con los controles posteriores de los pacientes. Además, explica que si bien es cierto que el no utilizó la colangiografía en la operación, ese sistema no se utiliza de rutina sino que es selectivo para algunos casos en el que cirujano lo considere necesario. Aclara, que el no lo consideró necesario, por eso no la realizó y que tampoco es un método que garantice por si solo el éxito en las operaciones. Además, sostiene que la misma actora reconoce que antes de cumplirse las dos semanas de la primera cirugía abandonó el tratamiento, y firmo su alta voluntaria para continuar tratándose con otros médicos en el Sanatorio Allende, cuestión esta, lo que constituye una ruptura del nexo causal, por el que no debe responder. Puesto a que es totalmente ajeno a todo lo que sucedió luego de que la actora se retirara de la Clínica Sucre.

Rechaza la existencia de los daños reclamados y su cuantificación. Cita en garantía a su aseguradora TPC Compañía de Seguros S.A.

4) A ff. 134/149 contesta la demanda la citada en garantía Noble Compañía de Seguros S.A. pidiendo su rechazo con costas. Acompaña póliza vigente a la fecha de los hechos a favor de la Clínica Sucre y denuncia la existencia de una franquicia. Solicita el rechazo de la demanda, con costas. Impugna documental. Realiza una negativa genérica y otra específica de los hechos relatados. Sostiene, que en la primera cirugía hubo una complicación relacionada a un proceso inflamatorio secundario a la litiasis. Explica, que el síndrome de Mirizzi determinó la desvitalización del conducto colédoco, lo que produjo una estenosis y filtración a través de una sutura, que requirió reintervención quirúrgica. Arguye, que en pleno tratamiento la paciente decidió en forma unilateral abandonarlo, lo que privó al médico actuante y a la Clínica Sucre de continuar con las atenciones médicas, todo lo que funciona como un eximente de responsabilidad para la parte por ellos representada.

5) A ff. 178/180 contesta la demanda la citada TPC Compañía de Seguros S.A. Acompaña copia de la póliza. Adhiere en todos sus términos a la contestación de demanda efectuada por su asegurado el demandado Dr. O.M. D'A.

6) A ff. 183/186 contesta el traslado la demandada Clínica Sucre, solicitando el rechazo de la demanda con costas. Impugna documental. Realiza negativa de los hechos. Sostiene, que no hubo negligencia, ni impericia ni ignorancia por parte del médico. Explica, que la actora fue debidamente informada acerca del procedimiento que se iba a realizar en la cirugía y de los posibles efectos y resultados de la misma y que prestó su libre consentimiento para ello. Sostiene, que en la primera cirugía hubo una complicación, previsible para este tipo de cirugía, lo que fue advertido después de la misma. Que luego

fue dada de alta, sin fiebre y con todos los parámetros técnicos necesarios para el alta médica. Indica, que en la segunda cirugía se intentó reparar la lesión biliar, pero que antes de que terminara su tratamiento la actora voluntariamente se trasladó a otro hospital, privando al médico tratante de terminar de realizar la reconstrucción.

7) A ff. 188/192 comparece la Sra. Fiscal Civil, Comercial y Laboral de 2.^a Nominación, manifestando que no hay relación de consumo entre la actora y el Dr. O.M. D'A, pero sí entre la actora y la Clínica Sucre y todas las aseguradoras.

8) A f. 213 se abre a prueba la causa, obrando en autos las que fueran diligenciadas.

9) Corridos los traslados para alegar, la actora lo evacua con fecha 21/09/2023, el demandado Dr. O.M. D'A y la citada TPC Compañía de Seguros S.A. lo evacúan con fecha 06/09/2023, la citada en garantía Noble Compañía de Seguros S.A. lo evacua con fecha 07/09/2023, la Sra. Agente Fiscal con fecha 05/03/2024 y con fecha 21/11/2023 se le da por decaído el derecho dejado de usar al no alegar a la demandada Clínica Sucre Centro de Cuidados Coronarios S.R.L.

10) Dictado el decreto de autos con fecha 20/03/2024 y firme el mismo, queda la causa en condiciones de ser resuelta.

Y CONSIDERANDO:

I) En primer lugar, cabe calificar la relación jurídica de la actora con la demandada Clínica Sucre, como un vínculo contractual de prestación del servicio privado de salud. Asimismo, y tal como lo dictaminara la Fiscal interviniente, este tipo de relación contractual se inserta en el ámbito de la Ley de Defensa del Consumidor, en virtud de que la actora es usuaria del servicio de salud prestado por el sanatorio demandado. Por lo tanto, le son aplicables los arts. 2, 5, 8 y 8 bis de la LDC, sin perjuicio de la garantía fundamental consagrada en el art. 42 de la Constitución Nacional, así como el art. 7 del

Código Civil y Comercial de la Nación, en cuanto prescribe que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en las relaciones de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Por otra parte, no hay dudas en la doctrina acerca de que la responsabilidad médica es contractual e implica la violación por parte del médico de una obligación principal que, en la generalidad de los casos es de medios, brindar “una atención diligente e idónea al enfermo, sobre la base de las reglas del arte de la medicina, sin asegurar que dicho resultado perseguido se vaya a lograr”. Mientras que respecto de la Clínica demandada, resulta de aplicación el régimen de responsabilidad objetiva y solidaria, derivada de daños de cosas o servicios, emergente del art. 40 de la ley 24240, que capta a todos los daños causados por el riesgo o vicio de las cosas y emergentes de servicios, siempre que sea defectuoso o riesgoso. Así, la responsabilidad de la institución por el hecho de sus dependientes no puede prescindir del análisis de existencia o no de responsabilidad en cabeza del dependiente. Se comparte lo manifestado por la Sra. Fiscal, acerca de que entre la clínica demandada y el médico tratante no existe una relación de consumo, puesto que al ser profesional su campo de actuación se encuentra excluido del ámbito de la Ley de Defensa al Consumidor.

II) Así, cabe comenzar con el análisis pormenorizado de la causa, mediante la valoración de las pruebas aportadas por las partes, conforme las reglas que informan la sana crítica racional. De tal manera, corresponde verificar si se dan en el caso los presupuestos de responsabilidad civil que ameriten el acogimiento de la demanda o, en su defecto, el rechazo. En tal sentido, es necesario definir en primer lugar y con la mayor claridad posible, las circunstancias fácticas que sustentan las actuaciones, luego determinar la

existencia del daño invocado como base de la pretensión, para después verificar -de corresponder- la existencia de nexo causal entre el hecho y el daño comprobado. En caso de verificarse la relación de causalidad habrá de establecerse la responsabilidad de los demandados y su factor de imputación para, finalmente, determinar la procedencia de los distintos rubros reclamados y su cuantía.

III) En el caso de autos, la actora fustiga el comportamiento del médico tratante el Dr. O.M. D'A, sosteniendo que varias de las conductas asumidas por el mismo configuraron mala praxis médica, las que serán analizadas separadamente y a continuación. Por ello, resulta de trascendental importancia establecer si hubo negligencia e impericia en el obrar del médico, a fin de determinar luego la responsabilidad del nosocomio, por lo que corresponderá analizar el material probatorio rendido en los autos, a fin de fijar la plataforma fáctica de la causa.

Corresponde recordar, que en las acciones por mala praxis médica la prueba documental consistente en la H.C. es de vital importancia. La misma consiste en un registro de datos médicos, sobre el diagnóstico, terapia y evolución de la enfermedad del paciente (Lorenzetti, Ricardo L., Responsabilidad civil de los médicos, t. II, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe 2016, p. 374). Esa prueba documental junto a la pericia médica, en consonancia con los demás elementos probatorios, suelen resultar fundamentales para dirimir la cuestión. Por lo tanto, es menester que patenten de la manera más evidente posible las circunstancias del caso y sus consecuencias.

En primer lugar, la actora sostiene que el Dr. O.M. D'A en la primera cirugía llevada a cabo en la Clínica Sucre cometió una injuria quirúrgica de las vías biliares Tipo I o II de Bismuth, consistente en que seccionó el conducto hepático común dejándolo abierto a la cavidad y ligó el conducto colédoco juntamente con el cístico. Sostiene, que es un grave error que debe ser considerado mala praxis médica. El COPRAMESAB, a ff. 912/915, es dilapidario en contra de esta primera afirmación de la actora, puesto que en el punto L donde se le pregunta acerca de lo sucedido en la cirugía del 04/09/2007, detallo: “[...] *Se ligó y seccionó la vía biliar provocando un coleperitoneo, sin advertir en el momento del acto dicha maniobra [...]*”. En el punto LL, se le pide al Comité Oficial que determine si la actora fue víctima de la injuria quirúrgica tipo I o II de Bismuto, a lo cual se responde: “[...] *De acuerdo a la documental aportada, no se puede precisar si fue una lesión tipo I o tipo II [...]*”. En el punto P, se le pregunta al Comité si el Dr. O.M. D'A incurrió en lesión quirúrgica de la vía biliar y en caso afirmativo, que explique cómo o en que circunstancias se produjo la misma, a lo que dictaminó: “[...] *Si se produjo lesión biliar, se puede interpretar que dicha lesión se produjo al identificar erróneamente el colédoco como si fuera el conducto cístico [...]*”. En el punto R, se le solicita al Comité que determine si las afecciones que presentó la actora son parte de un proceso natural o patológico de la misma, a lo que el cuerpo examinador, dictaminó: “[...] *Las afecciones que sufrió la actora pueden ocurrir en el contexto de una lesión quirúrgica de vía biliar, estas afecciones no son naturales, se producen en relación a la injuria de la vía biliar, y la lesión de la vía biliar son complicaciones que pueden ocurrir en este tipo de cirugía [...]*”. En cuanto al valor de estas conclusiones periciales, debe recordarse, en primer lugar, que la pericia oficial llevada a cabo representa la pieza probatoria más apta para dilucidar la cuestión sujeta a

decisión, por tratarse de la opinión de especialistas acerca del área propia de su conocimiento, sobre las cuales no es mucho lo que puede conocer el juez y por tratarse de auxiliares de la justicia, por lo que su dictamen luce imparcial y objetivo. Asimismo, el informe pericial se encuentra elaborado por el Dr. Guillermo G. Tillard y por el Dr. Joaquín Bastet, ambos médicos forenses, de lo que se desprende que sus conclusiones fueron elaboradas en conjunto por dos profesionales médicos. Por lo demás, el informe se encuentra debidamente fundado, habiendo realizado un análisis de todas las pruebas obrantes en autos. De todo lo expuesto, se deriva como primera conclusión, que en la primera cirugía realizada a la actora en la Clínica Sucre por el demandado Dr. O.M. D'A ocurrió una lesión de la vía biliar, pero que no se debió a ninguna inobservancia o impericia grave del médico tratante, sino que por el contrario, es una de las complicaciones que pueden surgir en una cirugía de vesícula por videolaparoscopia. Por otra parte, esas conclusiones periciales del organismo oficial, encuentran respaldo en otro elemento objetivo de prueba, esto es la declaración del Dr. M.C. (ff. 359/360), que es el médico que la operó por tercera y cuarta vez cuando la actora se fue al Sanatorio Allende. Así las cosas, en la pregunta n.º 4, el testigo explica: “[...] A la actora, la operaron en la Clínica Sucre de la vesícula, que se la sacaron y aparentemente en el acto quirúrgico se le produjo un pequeño desgarro en la vía biliar, que el cirujano prudentemente le puso un drenaje [...]”. Repreguntado el testigo acerca de si la lesión de la vía biliar, en una colescistectomía por video laparoscopia constituye una de las complicaciones que se puede presentar, enfáticamente declaró: “[...] Si, la chica tuvo la suerte porque a veces el cirujano no la detecta, y si la detecta, le coloca un tubo. Que ella vino con un tubo que drenaba la bilis que la coleccionaba, pero no toda como debía drenar, por eso la operamos. Que la vía biliar estaba abierta en la paciente, porque el

cirujano que la intervino primeramente por extraer la vesícula se le abrió la vía biliar. Que es una complicación que se puede presentar [...]”. Cabe mencionar, que la declaración del testigo se presenta clara, objetiva, fundada y no está impugnada. Además, tiene el gran valor convictivo de la testimonial calificada, puesto que se trata de un médico y especialista en el tema que nos ocupa. De todo lo que se infiere, que la lesión ocurrida en la primera cirugía fue una complicación que puede ocurrir en este tipo de operaciones, sin que exista ningún elemento técnico que apunte a acreditar ni siquiera a nivel indiciario, que la lesión se debió a alguna impericia del médico tratante o a algún error ni mucho menos a alguna inobservancia de algún procedimiento.

Cabe recordar, que la parte actora presentó un dictamen pericial en disidencia, presentada por el Dr. Tomás Antonio Ceballos (ff. 924/925 más la agregación de la foja faltante junto al alegato de la actora), en la que el médico manifiesta que no está de acuerdo con algunas expresiones del COPRAMESAB y detalla que el demandado cometió una mala praxis médica al lesionar la vía biliar en la cirugía. Pero es de vital importancia recalcar que no aclara en que radica esa observación, solo se limita a señalar que el médico no consigno en la foja quirúrgica de cirugía que se había producido una lesión. Y no menos cierto es, que como se explicó *ut supra* además de ser una de las complicaciones que pueden surgir en este tipo de cirugías, muchas veces los cirujanos no la advierten en el mismo momento, lo que explica claramente, la circunstancia de que no haya colocado el médico en la foja quirúrgica esa circunstancia. Por lo demás, las observaciones efectuadas por el perito de control, no alcanzan para desvirtuar la conclusión del Comité oficial, desde que su condición de perito de parte, no coloca sus conclusiones en la jerarquía de prueba de igual o mayor jerarquía a la del dictamen oficial. Sobre el punto el Tribunal Superior de Justicia tiene dicho que: “*ante dos opiniones contradictorias entre el perito oficial y el de control*

(ambos especialistas en la materia) debe prevalecer el del primero pues las garantías que rodean su designación (por el Tribunal y por sorteo) hacen presumir su mayor imparcialidad y consecuentemente mayor convicción. El perito de control –a diferencia del oficial- es un experto de confianza de la parte que lo propuso, y por lo tanto actúa más como defensor parcial que como auxiliar imparcial del juez” (T.S.J.Cba., Sala CyC in re: “CEPULVER JUAN PORFIRIO C/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA DIRECCIÓN DE AGUAS Y SANEAMIENTO (DAS) DAÑOS Y PERJUICIOS RECURSO DE CASACION” (C-05/04), Sent N° 57 del 07/08/07).

Por otra parte, es preciso mencionar que en sede penal también se produjo una pericia oficial, (ff. 51/55), la que en su pregunta n.º 1 acerca de lo sucedido en la cirugía, los galenos detallaron que se había producido una “Injuria Quirúrgica tipo I o II de Bismuth”. Este dato, coincide con lo dictaminado por el COPRAMESAB en esta sede civil, puesto que aquí los galenos establecieron que no se podía establecer con exactitud si fue una lesión tipo I o II. Lo que no dudan ambas periciales, es de la existencia de la lesión.

En segundo lugar, la actora fustiga que el demandado no advirtió que estaba produciendo la lesión en el momento de la laparoscopia, toda vez que no utilizó ningún método recomendado por la medicina para identificar los conductos y no cometer ese grave error, como es la colangiografía intraoperatoria. Cabe adelantar, que se trata de un embate que tampoco puede prosperar, ya que el COPRAMESAB en su punto n.º A se le solicita que determine si los tratamientos y procedimientos médicos y quirúrgicos efectuados a la actora por parte del Dr. O.M. D’A fueron los correctos y correspondientes al arte del buen curar o buena praxis médica, dictaminó: “[...]Si, la

indicación de realizar la colecistectomía por video laparoscopia fue la correcta, ya que la paciente presentaba litiasis vesicular, con episodios de cólicos biliares [...]”.

En su contestación, el médico tratante explicó que por las circunstancias del caso, no consideró que fuera necesario realizar una Colangiografía y que es un procedimiento que no se realiza de rutina cada vez que se hace una laparoscopia y que nada asegura que de haberlo realizado la lesión no hubiera tenido lugar. Esa explicación encuentra apoyatura en la respuesta al punto B de la pericia oficial del COPRAMESAB quien detalla: *“[...]la misma no es pedida rutinariamente, generalmente se solicita cuando hay alguna alteración bioquímica, ej. Colestasis, etc. Cuando la ecografía abdominal informa microlitiasis, y el paciente tuvo síntomas compatibles con cuadros de pancreatitis, para evaluar la posible presencia de cálculos en la vía biliar, pero es imposible garantizar que no se producirá alguna lesión de la vía biliar a pesar de tener dicho estudio [...]”.* Además, en forma enfática en la respuesta al punto G el Comité determina que *“[...]tampoco es una práctica imprescindible [...]”.*

Esta conclusión, también encuentra apoyatura en la pericia médica que se realizó en sede penal, en la que los galenos explicaron: *“[...] Para poder prevenir variantes anatómicas, cálculos en la vía biliar principal y alteraciones inherentes al Síndrome de Mirizzi, se puede utilizar la colangiografía operatoria, que en este caso no se utilizó. No se conocen las causas de ello, pero este estudio no es lo único que el cirujano puede hacer para evitar injurias quirúrgicas de la vía biliar principal [...]”.* De todo ello se concluye, sin hesitación alguna, que tampoco puede categorizarse como mala praxis médica la circunstancia de no haber utilizado la colangiografía operatoria, puesto como según se vió, no se trata de un procedimiento obligatorio ni de rutina para este tipo de cirugías, y

además (a estas alturas) es un elemento contra fáctico, puesto que de haberse realizado esa circunstancia por sí sola no permitiría asegurar que no se hubiera producido la lesión. Por otra parte, la actora funda parte de su reclamo en lo sucedido en la segunda cirugía, aduciendo que el Dr. O.M. D'A la volvió a operar por segunda vez, pero no solucionó el inconveniente que el mismo había producido en la primera cirugía, sino que solo le colocó un drenaje para que la bilis comenzara a salir al exterior. En atención a este argumento, que tampoco logra tener cabida en función de los elementos probatorios rendidos en la causa, cabe recordar que el COPRAMESAB en su respuesta al punto M, determinó: “[...]17/09/2007: Cirugía realizada por Dr. D'A en la Clínica Sucre laparotomía exploradora más lavado de cavidad, más drenaje biliar externo [...]”. De lo que se infiere, que si tiene razón la actora en cuanto manifiesta que le lavaron la cavidad y le pusieron un drenaje, pero lo dirimente aquí es desentrañar los motivos por los cuales el médico tomo esa actitud y si existía la posibilidad o no (en ese momento) de realizar la reconstrucción de la vía biliar. En ese punto, el COPRAMESAB en la respuesta al punto Q determinó: “[...]Se realizó un tratamiento correcto desde el momento de la detección de la lesión quirúrgica de la vía biliar, tomando el tiempo necesario para realizar la reparación diferida de la vía biliar [...]”. Pasaje este de la pericia científica que revela la necesidad de esperar un determinado tiempo para realizar la reparación de la vía biliar, indudablemente porque en el momento de realizarse la segunda cirugía, no se encontraban dadas las condiciones técnicas necesarias para proceder a la reparación. Ya que no existen elementos probatorios que indiquen ni siquiera indiciariamente que el médico a propósito, o con malicia o impericia, hubiera tomado la decisión de solo ponerle un catéter y no solucionar el inconveniente de la lesión biliar. Tampoco se entienden lo motivos, ni la finalidad por los cuales podría haber

llegado a tomar esa decisión. En este punto, resulta muy esclarecedor la testimonial del Dr. M.C., quien fue el médico que logro realizar la reparación de la vía biliar con posterioridad (luego de dos cirugías más) quien a ff. 359/360 preguntado acerca si el consideraba que en relación a las cirugías anteriores (es decir a las efectuadas por el demandado) se podía considerar que hubo mala praxis, respondió: “[...]Para mi, es una complicación intra operatoria y el doctor actuó bien, porque lo detectó durante la operación y le coloco un drenaje [...]”. Repreguntado el testigo acerca de porque no pudo reparar la lesión el otro médico en la segunda cirugía, explicó: “[...]Teóricamente se puede reparar, pero el médico prefirió dejar un drenaje prudentemente. Y además, dejo constancia que la lesión la detecto en la cirugía porque si no, no le hubiera puesto el drenaje [...]”. Estos últimos elementos fulminan las afirmaciones dadas por la actora acerca que el médico fue negligente en la segunda cirugía porque no reparó la vía sino que solo le colocó un drenaje.

Asimismo, la actora sostiene que en la foja quirúrgica de esa segunda cirugía, el medico maliciosamente consignó que había advertido la existencia del Síndrome de Mirizzi, lo que no era cierto, arguyendo que eso lo habría realizado el médico para ocultar la verdad de lo sucedido en la anterior operación. Corresponde mencionar, que si bien es cierto que de constancias del sumario penal surge que en la foja quirúrgica de la segunda cirugía el Dr. O.M. D’A hizo referencia a la posible existencia del Síndrome de Mirizzi, no menos cierto es que los mismos peritos técnicos en sede penal dictaminaron: “[...]Hacer un diagnóstico retrospectivo del Síndrome de Mirizzi carece de sentido práctico, pues es sólo una especulación de lo que pudo haber sucedido, a tal punto que esto no es mencionado por el segundo cirujano [...]”. Vinculado a este argumento, cabe recordar que lo que está en juego aquí, es la actitud y los procedimientos realizados en la

segunda cirugía, los cuales según se vio, fueron necesarios para ese momento. Y no, calificar si fue correcto o no un presunto diagnóstico que el médico consignó en la foja quirúrgica de la operación.

Por último, naufraga el argumento intentado por la actora acerca de que el Dr. O.M. D'A obró con mala fé y que maliciosamente le oculto información, puesto que ella misma en un pasaje de su demanda reconoce que luego de salir de la segunda cirugía, el médico tratante habló con un tío de la actora y le explicó la realidad de todo lo sucedido. Asimismo, la actora reconoce que luego de que ella firmara voluntariamente su alta médica para dirigirse a atenderse en el Sanatorio Allende, recibió una visita en ese nosocomio, del Dr. O.M. D'A para interiorizarse de su estado de salud y su evolución, circunstancia esta, que sin mayores esfuerzos interpretativos revela que el médico no actuó con mala fe, ni en forma displicente con la actora en ningún momento.

De todo lo expuesto, se deriva que no se le puede reprochar objetiva o válidamente ninguna omisión ni observancia u error inexcusable en su accionar médico al demandado Dr. O.M. D'A, con lo que indudablemente la demanda no puede prosperar en su contra, puesto que no se ha acreditado la mala praxis sostenida por la actora en su libelo introductivo.

Resta mencionar, y solo como argumento accesorio a las conclusiones arriba apuntadas en relación a la inexistencia de mala praxis médica, que ha quedado acreditado en la causa que la actora a la fecha de la pericia oficial no tiene incapacidad alguna derivada de todos los sucesos acontecidos, puesto que el COPRAMESAB indicó que: *"[...]Desde el punto de vista médico y desde el punto de vista médico laboral, la actora puede seguir el curso normal de su vida en lo cotidiano y con respecto a su vida laboral también la puede*

desarrollar sin problema. Con respecto al porcentual actual de incapacidad es del 0% [...]”. Por lo que indudablemente y solo para el caso que se hubiere comprobado que el demandado incurrió en mala praxis en su accionar, luego se revelaría (en un estado hipotético de análisis) la cuestión de la inexistencia del nexo causal adecuado entre su accionar y el daño ocurrido. Como fuere, en este caso no tiene incidencia alguna, ya que como según se vió, con toda la prueba colectada se ha acreditado que no hubo mala praxis médica.

Finalmente, no es ocioso destacar que en la causa no se ha observado ninguna actitud reprochable a la Clínica Sucre en cuanto a la responsabilidad objetiva como proveedor de un servicio médico, puesto que no se ha revelado ningún incumplimiento a la Ley de Defensa al Consumidor. Asimismo, la actora no se ha agraviado en cuanto a la falta del deber de información por parte de la Clínica, sino que puntualizo toda su responsabilidad en la mala praxis del médico tratante.

En consecuencia y habiéndose acreditado que no hubo negligencia o descuido, ni inobservancia u error grave por parte del accionar del Dr. O.M. D’A y por lo tanto, no existiendo responsabilidad refleja por parte del nosocomio demandado, como así tampoco se ha acreditado algún indebido accionar de la Clínica Sucre en cuanto a su obligación como prestadora de servicio de salud, no queda otra alternativa que el rechazo de la acción en contra del O.M. D’A y en contra de Clínica Sucre.

IV) En cuanto a las costas, pese a que no fue acreditada la culpa del demandado ni de la clínica accionada, se observa que la actora hizo una denuncia penal luego de lo sucedido, lo que revela una conducta coherente y habitual de alguien que está convencido de que ha sido víctima de un delito o por lo menos de un indebido accionar. Además, en la pericia

médica realizada en el sumario penal, los especialistas al detallar lo sucedido en la primera cirugía detallaron que “esa lesión fue producida por el cirujano y no fue advertida por el mismo durante la video laparoscopia”, luego referenciaron que hubo una “tórpid y complicada evolución postoperatoria de la primera cirugía”. Estos términos, pueden motivar a una persona que no es médica y que por lo tanto no tiene conocimientos específicos en la materia, a pensar con cierto y razonable grado de seguridad que la lesión producida por el médico en la cirugía fue debido a un error inexcusable o impericia del mismo y además, que fue el origen de todas las complicaciones posteriores, generando por consiguiente la convicción de tener derecho a reclamar, lo que justifica que las costas se impongan por su orden.

V) A los fines de practicar las regulaciones de honorarios de los letrados de los demandados se debe tomar como base el monto demandado (art. 31 inc. 2° del C.A.) y adicionarle sus intereses, conforme a lo solicitado en la demanda. De ese modo, el rubro gastos médicos y de movilidad, por el que la actora solicitó la suma de pesos diez mil (\$ 10 000) se actualizará desde la fecha del hecho, igualmente que el rubro gastos por terapia psicológica por el que se reclama la suma de pesos doscientos cuarenta y siete mil doscientos (\$ 247 200). En relación al rubro lucro cesante pasado, por el que se reclama la suma de pesos setecientos sesenta mil doscientos setenta y nueve con veintiséis centavos (\$ 760 279,26) se tomará el monto mensual resultante de cada mes vencido y se actualizará desde que cada suma fue debida, desde la producción del hecho hasta el dictado de la presente sentencia. En relación al rubro lucro cesante futuro, por el que se reclama la suma de pesos diez millones cuarenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y dos con ochenta y seis centavos (\$ 10 047 452,86), no se actualizará conforme tratarse un rubro futuro y en relación al daño moral por el que se reclama la suma de pesos doce

millones doscientos setenta y dos mil seiscientos (\$ 12 272 600) será actualizado desde la fecha del alegato, puesto que se cuantifico a valores actuales a ese momento (21/09/2023). Así las cosas, la base para regular los honorarios de los abogados de los demandados, asciende a la suma de pesos

sesenta y cuatro millones seiscientos cuatro mil seiscientos noventa y dos con dieciocho centavos (\$ 64 604 692,18). Teniendo en cuenta la cuantía del asunto, conjugados con las demás reglas de evaluación cualitativas establecidas por el art. 39 de la ley 9459, se estima adecuado a la justicia del caso aplicar medio punto sobre el punto medio de la escala del art. 36 (resultando aplicable la segunda escala del citado artículo, el porcentaje a utilizar es el 22%). Realizadas las operaciones correspondientes se obtiene el importe de pesos catorce millones doscientos trece mil treinta y dos con veintisiete centavos (\$ 14 213 032,27) en que corresponde regular los honorarios profesionales del Dr. Gastón E. Acevedo quien participa en representación del demandado Dr. O.M. D'A y de la citada en TPC Compañía de Seguros S.A. Asimismo, corresponde practicar idéntica regulación a los abogados de citada Noble Compañía de Seguros S.A.: el Dr. Gonzalo José Cabanillas, Dr. Fernando L. Careto Loza (hoy fallecido) y Dra. Celia Elisa Cerutti (en conjunto y proporción de ley). Además, en relación a los abogados de la demandada Clínica Sucre Centro de Cuidados Coronarios S.R.L., esto es el Dr. Fabián Gabriel Barberá y Dr. Manuel M. Reyna Sarsfield, deberá recordarse que solo contestaron la demanda, por lo que corresponde regular definitivamente en conjunto y proporción a ambos letrados el 40% de la regulación correspondiente, en función de lo establecido en el art. 45 del C.A., esto es la suma de pesos cinco millones seiscientos ochenta y cinco mil doscientos doce con noventa centavos (\$ 5 685 212, 90). A los fines de la regulación de los honorarios de la parte actora, se tomará como base un porcentaje del monto

demandado y sus intereses (art. 31 inc. 1° del C.A.), esto es el 25%, resultando un monto de pesos dieciséis millones ciento cincuenta y un mil ciento setenta y tres con cuatro centavos (\$ 16 151 173,04). Teniendo en cuenta la cuantía del asunto, conjugados con las demás reglas de evaluación cualitativas establecidas por el art. 39 de la ley 9459, se estima adecuado a la justicia del caso aplicar medio punto menos del punto medio de la escala del art. 36 (resultando aplicable la primera escala del citado artículo, el porcentaje a utilizar es el 22%). Realizadas las operaciones correspondientes se obtiene el importe de pesos tres millones quinientos cincuenta y tres mil doscientos cincuenta y ocho con seis centavos (\$ 3 553 258,06) en que deben regularse los honorarios en conjunto y proporción de ley a la Dra. Norma Gladys Ferreyra y Dr. Andrés Roberto Ricaldone. A los fines de la regulación de honorarios del perito psiquiatra oficial Dr. Carlos Eleazar Garzón se cuantificarán sus honorarios en el valor de 12 jus atento a las reglas de evaluación cualitativas establecidas por el art. 39 de la ley 9459. Se deja constancia de que todos los honorarios aquí regulados, tienen el carácter de definitivos y generarán intereses desde la fecha de la presente resolución, según la tasa pasiva promedio mensual que publica el BCRA con más el 3% nominal mensual hasta su efectivo pago.

Por lo expuesto, normas legales citadas y arts. 26, 31, 36, 39 de la ley 9459.

SE RESUELVE:

- 1.º) Rechazar la demanda de daños y perjuicios por mala praxis promovida por la Sra. M.L. V., con costas por su orden.
- 2.º) Regular, de manera definitiva, los honorarios del Dr. Gastón E. Acevedo en la suma de pesos catorce millones doscientos trece mil treinta y dos con veintisiete centavos (\$ 14 213 032,27) con más el IVA en caso de corresponder, esto es, si al tiempo del pago dicho profesional reviste la calidad de inscripto ante la AFIP. Regular, de manera

definitiva, en conjunto y proporción de ley, los honorarios del Dr. Gonzalo José Cabanillas, Dr. Fernando L. Careto Loza (hoy fallecido) y Dra. Celia Elisa Cerutti en la suma de pesos catorce millones doscientos trece mil treinta y dos con veintisiete centavos (\$ 14 213 032,27) con más el IVA en caso de corresponder, esto es, si al tiempo del pago dichos profesionales revisten la calidad de inscriptos ante la AFIP. Regular, de manera definitiva, en conjunto y proporción de ley, los honorarios del Dr. Fabián Gabriel Barberá y Dr. Manuel M. Reyna Sarsfield, en la suma de pesos cinco millones seiscientos ochenta y cinco mil doscientos doce con noventa centavos (\$ 5 685 212, 90) con más el IVA en caso de corresponder, esto es, si al tiempo del pago dichos profesionales revisten la calidad de inscriptos ante la AFIP. Regular, de manera definitiva, en conjunto y proporción de ley, los honorarios de la Dra. Norma Gladys Ferreyra y Dr. Andrés Roberto Ricaldone en la suma de pesos tres millones quinientos cincuenta y tres mil doscientos cincuenta y ocho con seis centavos (\$ 3 553 258,06) con más el IVA en caso de corresponder, esto es, si al tiempo del pago dichos profesionales revisten la calidad de inscriptos ante la AFIP. Regular, de manera definitiva, los honorarios del perito psiquiatra oficial Dr. Carlos Eleazar Garzón en la suma de pesos trescientos ochenta y un mil trescientos diecisiete con cuatro centavos (\$ 381 317,04) con más el IVA en caso de corresponder, esto es, si al tiempo del pago dicho profesional reviste la calidad de inscripto ante la AFIP.

Protocolícese y dese copia.-